

1503124-26.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... elemento subjetivo do tipo penal referente ao narcotráfico.

Não há dúvidas de que os comportamentos perpetrados pelos réus se amoldam perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, "a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503124-26.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503124-26.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2259475/2021 - 01º D.P. CUBATÃO, 20419300 - 01º D.P. CUBATÃO, 547/21/228 - 01º D.P. CUBATÃO, 2259475 - 01º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO EDSON OLIVEIRA CASTRO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHS FAVERO

I - RELATÓRIO

FRANCISCO EDSON OLIVEIRA CASTRO e LEONARDO KAUÊ DE VASCONCELOS SANTOS foram denunciados e estão sendo processados por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006, c.c. o artigo 29, "caput", do Código Penal.

Isto porque, segundo a denúncia, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 08h00, na Rua Marina Lourenço de Oliveira, Bolsão 07, Cubatão, FRANCISCO EDSON OLIVEIRA CASTRO, qualificado a fls. 28, e LEONARDO KAUÊ DE VASCONCELOS SANTOS,

qualificado a fls. 29, agindo previamente ajustados, com identidade de propósitos e desígnios e divisão de tarefas, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, maconha, cocaína e "crack", causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 07/08, auto de constatação preliminar de fls. 09/10 e laudo definitivo das drogas de fls. 109/111. Segundo o apurado, policiais civis, durante atuação de campo, em uma viatura descaracterizada, realizaram uma breve campanha, próximo ao local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram o denunciado LEONARDO, com uma mochila nas costas, e o denunciado FRANCISCO segurando um rádio comunicador HT, em uma das mãos, ambos em via pública, em atitude típica de tráfico de drogas. Em seguida, visualizaram um usuário de droga se aproximando do local e, após breve interlocução com os denunciados, LEONARDO adentrou no estacionamento do conjunto habitacional, permaneceu, por alguns instantes, atrás de um muro, retornou com algo na mão e entregou ao usuário, que, por sua vez, entregou algo para FRANCISCO. Em dado momento, desembarcaram da viatura, se aproximaram e fizeram a abordagem dos denunciados, os quais esboçaram uma tentativa de fuga, mas foram, imediatamente, detidos. Em poder de FRANCISCO, foi apreendido o rádio comunicador, anteriormente visualizado, preso a sua cintura. Já na mochila, que LEONARDO portava, logrou-se êxito em localizar, em seu interior, um notebook, pertencente à Secretaria de Educação de Cubatão (elaborado outro boletim de ocorrência n.º 552/21 - fls. 06 e 106/107). Por fim, feita a varredura, no interior do estacionamento que LEONARDO havia permanecido, por alguns instantes, localizaram, atrás do muro, escondido, em um jardim, uma sacola plástica contendo, em seu interior, 11 (onze) porções de maconha (peso bruto - 0,30g), 12 (doze) pedras de "crack" (peso bruto - 0,1g) e 05 (cinco) pinos contendo cocaína (peso bruto - 0,1g). A razoável quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados, o modo de acondicionamento (fracionadas e previamente embaladas, prontas para o comércio), as circunstâncias da apreensão e os testemunhos dos policiais, demonstram que os denunciados praticavam o tráfico ilícito de entorpecentes. A denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2021 (fls. 126/130). Os acusados foram citados e apresentaram defesa prévia (fls. 163/164). Juntada suas folhas de antecedentes em fls. 54/61 e 64/66. Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas. Ao final, os réus foram interrogados. Em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a aplicação de regime inicial diverso do fechado e a suspensão condicional da pena. É o breve relatório. Fundamento e decido.

II - PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório dos acusados. Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais. Inicialmente, gizo que incabível a alegação de que o flagrante foi preparado. O flagrante provocado ou preparado é aquele em que ocorre a indução ou instigação para que agente cometa o crime, com o fito de se efetuar a prisão. Como ensina RENATO BRASILEIRO DE LIMA, o flagrante preparado, também chamado de provocado, crime de ensaio, delito de experiência ou delito putativo por obra do agente provocador, "ocorre quando alguém (particular ou autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consuma". (Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador:JusPodivm, 2020, p. 1.035.)

A atuação dos policiais, como se vê, não se amolda à figura do flagrante preparado, mas sim ao que na doutrina convencionou-se chamar de flagrante esperado, em que, "valendo-se de investigação anterior, sem a utilização de um agente provocador, a autoridade policial ou terceiro limita-se a aguardar o momento do cometimento do delito para efetuar a prisão em flagrante" (Manual de Processo Penal. 8ª ed. Salvador:JusPodivm, 2020, p. 1.036).

Assim, dos fatos narrados restou evidente que não houve qualquer tipo de preparação dos agentes policiais para que os Réus cometessem o crime. Não houve qualquer provocação escrupulosamente engengrada, a ensejar o nascedouro ou a gênese da intenção ou volição dos Réus para a prática ou consecução das condutas. Ao contrário, os agentes policiais estavam em patrulhamento e perceberam a ocorrência. Em verdade, o que poderia ter no caso em tela, é um verdadeiro flagrante diferido (ação controlada), conforme previsão contida no art. 53, inc. II da Lei 11.343/06 e no art. 3º, inc. III da Lei nº 12.850/2013. Afinal, esta modalidade de obtenção probatória consiste "em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações" (art. 8º da Lei 12.850/2013).

Logo, o crime – que é permanente – já estava sendo praticado antes mesmo da chegada dos policiais. Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça que se aplica perfeitamente à espécie:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ QUE SE CONFUNDIR FLAGRANTE PREPARADO COM FLAGRANTE ESPERADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. 1. Não se deve confundir flagrante preparado com esperado – em que a atividade policial é apenas de alerta, sem instigar qualquer mecanismo causal da infração. 2. A 'campana' realizada pelos policiais a espera dos fatos não se amolda à figura do flagrante preparado, porquanto não houve a instigação e tampouco a preparação do ato, mas apenas o exercício pelos milicianos de vigilância na conduta do agente criminoso tão-somente a espera da prática da infração penal. (...) 6. Writ denegado (HC 40.436/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2006, DJ 02/05/2006, p. 343).

Ademais, não há quaisquer nulidades quanto a prisão em flagrante, posto que a mesma já fora analisada na audiência de custódia, sendo inclusive homologada. Ultrapassada essa questão prévia, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III – MÉRITO

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente pelos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC – e aplicados ao processo penal na forma do art. 3º do CPP – passo a analisar todas as causas de pedir da acusação e teses defensivas. Destarte, passo ao exame da questão de fundo, aditando que a pretensão punitiva é procedente.

Consente-se que simbolicamente a Lei 11.343, que revogou a Lei 6.368/76 "representa uma nova política na seara das drogas" (HASSON, Felipe. Drogas: Constituição, Democracia e Liberdade. Curitiba: Instituto Memória. Centro de Estudos da Contemporaneidade, 2015.p. 156).

Na seara do Direito Penal, afirmam Zaffaroni e Pierangelli: "todo direito quer regular a conduta humana em sociedade e comina para que os homens se adaptem a suas regulações. Portanto, também, o direito penal tem uma aspiração ética: aspira evitar o cometimento e repetição de ações que afetam de forma intolerável os bens jurídicos penalmente tutelados" (Manual de Direito Penal Brasileiro - Parte Geral. 10ª ed. São Paulo: Editora Revistados Tribunais, 2013. p. 95).

A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., REsp. 1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de prova colhidos no Inquérito Policial: boletim de ocorrência (fls. 04/06 e 106/107), auto de exibição/apreensão (fls. 07/08), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 09/10), termo de depoimento (fls. 11/13), relatório final (fls. 103/104 e 112/113), laudo definitivo das drogas (fls. 109/111), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição aos réus, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Demais, adotando-se o conceito complexo do tipo de Hans Welzel, tem-se que ele apresenta um aspecto objetivo e outro subjetivo. Na ação penal típica, está implícito um juízo de valor. O tipo penal, deste modo, não é composto apenas por elementos objetivos, mas é também integrado por elementos normativos e subjetivos, que vão contornando o conteúdo material do injusto e identificando o bem jurídico tutelado. Em síntese, é a efetiva lesão ao bem jurídico que conduz o intérprete nos caminhos na tipicidade, como se minudenciara.

Vejamos:

Em solo policial, o condutor e testemunha CHRISTIANE MARTINIANO DE SOUZA disse que “na manhã de hoje, acompanhada do Investigador de Polícia Christian, realizava campanha do interior de uma viatura descaracterizada, próximo a uma “biqueira” de venda de drogas em um dos conjuntos habitacionais do Bolsão 07, em Cubatão. Após determinado tempo de observação, avistaram os dois indiciados, sendo que o indiciado Leonardo estava com uma mochila nas costas e o indiciado Francisco segurava um rádio comunicador HT em uma das mãos. Tal situação chamou a atenção da depoente e seu colega, pois a mochila poderia conter droga em seu interior e o rádio comunicador é comumente utilizado por traficantes para avisar a chegada da Polícia. Durante a observação, um indivíduo que parecia ser um viciado no uso de drogas aproximou-se dos indiciados e, após uma breve interlocução, o indiciado Leonardo adentrou no estacionamento do conjunto habitacional e, após permanecer alguns segundos atrás de um muro, retornou com algo na mão e entregou ao viciado, que por sua vez pareceu entregar algo para o indiciado Francisco. Convictos que tal situação era uma venda de drogas, a depoente e seu colega desembarcaram da viatura e abordaram os indiciados, identificando-se como policiais. Neste instante, os indiciados tentaram fugir, e a depoente segurou o indiciado Francisco, enquanto o policial Christian segurou o indiciado Leonardo. Durante a tentativa de fuga, a depoente acabou caindo ao solo enquanto segurava Francisco, o que causou-lhe uma luxação no pé direito. Em poder do indiciado Francisco a depoente apreendeu o rádio comunicador preso a sua cintura, enquanto o policial Christian apreendeu a mochila que estava com o indiciado Leonardo, constatando que em seu interior havia um notebook com número de patrimônio da Secretaria de Educação de Cubatão, além de um pendrive. Na continuidade, o policial Christian dirigiu-se ao interior do estacionamento onde, atrás do muro, escondido em um jardim, apreendeu uma sacola plástica contendo em seu interior 05 pinos de Cocaína, 10 porções em formato de tiras embaladas em plástico contendo Maconha, 12 porções de Crack embaladas em plástico e 01 porção de Maconha. Diante dos fatos, deram voz de prisão aos dois indiciados, conduzindo os mesmos a presença da Autoridade Policial” (fls. 11). Em Juízo, disse que se recorda dos fatos. Reconhece ambos os Réus. Na data dos fatos, por volta das 7h30 – 8h00 da manhã estava com o policial Christian, em viatura descaracterizada, a distância. Ficaram observando ambos. Leonardo estava

com uma mochila com as costas e Francisco estava com um rádio comunicador, na função de olheiro. Leonardo entrava nos prédios comunitários do CDHU e pegou algo, posteriormente entregando para um indivíduo, que aparentava ser usuário de drogas. Resolveram efetivar a abordagem. Dentro da mochila de Leonardo havia um notebook furtado da escola. O Policial Christian adentrou no CDHU e visualizou onde as drogas estavam escondidas. Teve o tornozelo machucado na abordagem. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. A diligência foi uma operação policial rotineira. Os Réus foram avistados juntos. Os Réus estavam juntos, de comum acordo, porque conversaram a todo momento. A droga, salvo engano, foi localizada logo atrás ao muro, na entrada do jardim do CDHU, salvo engano. As drogas estavam embaladas para mercancia. Os réus, indagados, permaneceram em silêncio. Não conhecia os Réus de abordagens anteriores.

Em solo policial, a testemunha CHRISTIAN BELTRAME DE SOUZA disse que “na manhã de hoje, acompanhado da Investigadora de Polícia Christiane, realizava campana do interior de uma viatura descaracterizada, próximo a uma “biqueira” de venda de drogas em um dos conjuntos habitacionais do Bolsão 07, em Cubatão. Após determinado tempo de observação, avistaram os dois indiciados, sendo que o indiciado Leonardo estava com uma mochila nas costas e o indiciado Francisco segurava um rádio comunicador HT em uma das mãos. Tal situação chamou a atenção do depoente e de sua colega, pois a mochila poderia conter droga em seu interior e o rádio comunicador é comumente utilizado por traficantes para avisar a chegada da Polícia. Durante a observação, um indivíduo que parecia ser um viciado no uso de drogas aproximou-se dos indiciados e, após um rápido diálogo, o indiciado Leonardo adentrou no estacionamento do conjunto habitacional e, após permanecer alguns segundos atrás de um muro, retornou com algo na mão e entregou ao viciado, que por sua vez pareceu entregar algo para o indiciado Francisco, que o tempo tempo permaneceu ali na função de “olheiro”. Convictos que tal situação era uma venda de drogas, a depoente e seu colega desembarcaram da viatura e abordaram os indiciados, identificando-se como policiais. Neste instante, os indiciados tentaram fugir, e a policial Christiane segurou o indiciado Francisco, enquanto o depoente Christian segurou o indiciado Leonardo. Durante a tentativa de fuga, a policial Christiane acabou caindo ao solo enquanto segurava o indiciado Francisco, o que causou-lhe uma luxação no pé direito. Em poder do indiciado Francisco foi apreendido o rádio comunicador preso em sua cintura, enquanto o depoente apreendeu a mochila com o indiciado Leonardo, constatando que em seu interior havia um notebook com número de patrimônio da Secretaria de Educação de Cubatão, além de um pendrive. Na continuidade, o depoente dirigiu-se ao interior do estacionamento onde, atrás do muro, escondido em um jardim, apreendeu uma sacola plástica contendo em seu interior 05 pinos de Cocaína, 10 porções em formato de tiras embaladas em plástico contendo Maconha, 12 porções de Crack embaladas em plástico e 01 porção de Maconha. Diante dos fatos, deram voz de prisão aos dois indiciados, conduzindo os mesmos a presença da Autoridade Policial” (fls. 13).

Em Juízo, reiterou a versão apresentada em solo policial e o quanto informado por seu colega de farda, agora sob o manto do contraditório.

Em solo policial, o acusado FRANCISCO EDSON OLIVEIRA CASTRO disse que “que presente o interrogando informando que saiu do bairro Vila Esperança, e caminhava quando localizou no matagal um rádio HT e que diante deste fato decidiu pegá-lo. Que, em seguida saiu deste bairro e foi para o bolsão onde foi abordado pelos policiais, os quais localizaram em seu poder tal aparelho, e que não tinha em seu poder nenhum entorpecente. Que, foi para o bolsão levar dinheiro para seu filho” (fls. 14/15). Interrogado em Juízo, disse que a acusação é falsa. Desconhece a droga. Estava passando pelo local. Achou o rádio no lixo, na avenida. Não sabe que o local é ponto de tráfico. Estava indo para sua mãe levar dinheiro. Trabalhava com reciclagem, procurando latinhas. Desconhece Leonardo. É usuário de crack e cocaína. Trocaria o rádio por droga. Mora na Vila Esperança. Estava indo levar dinheiro para seu filho. Desconhecia os policiais e acredita que não teriam nenhum motivo para incriminá-lo. No local dos fatos não existia nenhum outro indivíduo além de Leonardo.

Em solo policial, o acusado LEONARDO KAUÊ DE VASCONCELOS SANTOS disse que “Que em

seu poder não tinha nenhum entorpecente e que estava somente com o aparelho notebook, o qual sabia que era produto de furto e que estava no local dos fatos para revendê-lo." (fls. 16/17).

Interrogado em Juízo, disse que no dia da prisão havia furtado o notebook da prefeitura. É usuário de drogas. Pegou o notebook para trocar por drogas. Entrou no portão do prédio para mostrar o notebook e trocar por droga. No dia prisão mentiu que havia comprado o notebook. Não estava vendendo droga. Não havia droga nenhuma consigo no momento. Não conhecia o Corréu Francisco. Viu apenas Francisco no dia dos fatos. Não sabe dizer o que Francisco fazia na localidade. Ficou esperando alguém aparecer para comprar droga. É morador do Bairro. Francisco estava no local que é venda de ponto de droga. Francisco não disse o que estava fazendo na localidade. Nunca havia visto Francisco na localidade. Não conhecia os policiais que o prenderam.

Pois bem.

Finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que os réus praticaram o crime descrito na denúncia, pois as versões apresentadas pelos Réus não encontram eco no manancial probatório, quedando-se isolada.

Ademais, a comprovação da natureza entorpecente da substância, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada por perito criminal, o que ocorreu no caso em tela (art. 158 do CPP).

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo do tráfico de drogas é tipo congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo específico da mercancia. O tipo do art. 28 da Lei n. 11343/06, este sim, é tipo incongruente, em que o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige a comprovação do elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se tão somente que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia (STJ, REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

E, a despeito de entendimento pessoal em sentido contrário quanto à suficiência dos depoimentos policiais para sustentar a condenação, curvo-me ao entendimento dominante em respeito à isonomia, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (art. 926 do CPC, aplicado na forma do art. 3º do CPP).

O depoimento dos policiais civis deve ser bem avaliado. É verdade que, sem pretender qualquer crítica, sabe-se que a atuação policial é uma atividade administrativa que se situa em um contexto de tensão de direitos fundamentais, de modo que seria ingenuidade recorrer acriticamente ao dogma da presunção de regularidade dos atos dos agentes dos poderes públicos, confundindo vigência (existência do ato e regularidade formal) com validade (conteúdo material constitucionalmente conformado).

Neste sentido, LUGI FERRAJOLI destaca que "diversamente dos outros ramos da administração pública, é uma atividade em contato direto com as liberdades fundamentais" (Diritto e Ragione. 1998, p. 798, em tradução livre).

Dogmaticamente, o art. 202 do CPP perluastra que "toda pessoa poderá ser testemunha". Ademais, demais, quanto à questão da suspeição de uma testemunha policial, temos que, dada a aplicação do princípio da igualdade (art. 5º, caput e inc. I da CRFB), a mesma estará sujeita tal qual como qualquer outra testemunha ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP). Ora, "a qualidade da testemunha, seu meio de vida, sua profissão, sua reputação ou qualquer outro atributo pessoal não deve produzir efeito algum para impedir a sua atuação" (NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 98). A partir daí, parece evidente que o depoimento de policial somente poderia ser excluído da apreciação judicial se, desde logo, houvesse prova no sentido de que ele tivesse sido colhido em desrespeito às normas materiais – caso em que a prova deveria ser desentranhada dos autos (art. 157, CPP) –, ou às normas processuais, caso em que o ato seria nulo (art. 563 do CPP).

Entretanto, no caso em apreço, a palavra dos policiais merece a credibilidade dos testemunhos em geral, sendo que não há elementos seguros e convincentes que afastam

a confiabilidade de tais depoimentos, sobretudo porque o amplo acervo probatório arrolados nos autos encontra-se em consonância com os relatos dos agentes. Com efeito, observa-se que os testemunhos dos funcionários da polícia são harmônicos e descrevem os fatos com clareza, sendo que não há nenhum elemento capaz de colocar tais declarações em dúvida. Essas palavras, produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar os acusados – sobretudo porque nada foi levantado neste sentido –, soa mais que suficientes para embasar a condenação, pois, consoante iterativa jurisprudência, nada impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais. Sobre o tema, já decidiu Col. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório ameadado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); “...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, “o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).” (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

Não há nos autos nenhuma informação de que os policiais pretendessem imputar falsamente aos acusados a prática do crime descrito na denúncia, não havendo, portanto, provas que retirem a credibilidade de seus depoimentos. Dúvida não há acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelos acusados. Os relatos comprovam a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, sobretudo porque se trata de delito de tipo misto alternativo, em que a prática de apenas um dos verbos constantes no preceito primário é bastante para a sua caracterização.

Nos termos do art. 28, § 2º da Lei de Regência, notadamente as condições em que se desenvolveram as ações criminosas, denota-se que os acusados, de forma deliberada, guardavam e tinham em depósito drogas – verbos nucleares do preceito primário contido no art. 33 –, em elevadíssima quantidade, que seriam distribuídas pelo estado, pelo que é nítida a existência do elemento subjetivo do tipo penal referente ao narcotráfico.

Não há dúvidas de que os comportamentos perpetrados pelos réus se amoldam perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1ª T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Cumprе ressaltar que o crime em comento é do tipo misto alternativo, ou seja, o tipo penal é composto por inúmeros verbos – importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, vender, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar – que praticados isolada ou conjuntamente, implicam o cometimento de um crime único, ou seja, basta a prática de apenas uma dessas condutas para que o delito em tela consumar-se. Assim, o ato de “guardar” é apenas umas das condutas

que se subsumam ao tipo penal. Sendo desnecessário que os réus sejam encontrados no momento que realizam a comercialização do entorpecente, mesmo porque, esse ato, via de regra, se desenvolve na clandestinidade e, no caso em tela, os acusados foram abordados em razão de um patrulhamento policial.

Logo, é inviável se cogitar a absolvição por falta de provas ou negativa de autoria dos acusados em relação à imputação da prática do delito em comento. Igualmente não há que se falar em atipicidade da conduta.

Eventual tese de desclassificação para o art. 37 da Lei de Regência deve ser afastada em relação aos Réus, igualmente, isto porque no tráfico de drogas existem diversas funções na referida associação e que são divididas de forma a alcançar o desiderato principal.

Ora, dentre várias funções encontradas podemos citar o gerente, o passador, o radinho, o fogueteiro, a mula, o armeiro e também o denominado "olheiro", que era exatamente a função do Réu Francisco.

Destarte, se todos contribuem de alguma forma para o tráfico e fazem parte da referida associação, em verdade são coautores do delito. Com efeito, o intuito do legislador ao adotar no tipo penal do art. 37 da Lei 11.343/06, a teoria pluralista/pluralística não foi de alcançar o referido olheiro, pois este é coautor da conduta descrita no art. 33, mas, sim, aqueles que normalmente não integram a associação em suas diversas funções hierárquicas – mas acabam colaborando com informações que são consideradas estratégicas para o exercício da narcotraficância, notadamente aquelas que informam sobre futuras incursões policiais nas localidades do tráfico ou prestam colaboração de outras naturezas, sobretudo informacionais.

Adiante que, no caso em análise, é inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque o objetivo do aludido dispositivo de lei é privilegiar a figura comumente denominada por pequeno traficante ou traficante eventual, que pouco se dedica ao comércio espúrio e, quando o faz, realiza em pequena quantidade de drogas.

Assim, considerando tudo que foi exposto, isto é, as circunstâncias que se desenvolveram os fatos, aliados com as informações prestadas em Juízo pelas testemunhas, não restam dúvidas da materialidade do delito praticado pelos Réus. De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento dos Réus, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Impõe-se, portanto, a condenação dos acusados por infração ao artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, "caput", do Código Penal.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

Bem delineadas tais premissas, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI da CRFB) e ao sistema trifásico de Nelson Hungria (arts. 59 e 58 do CP), passo a dosar a reprimenda a ser imposta.

IV.I - Em relação ao réu FRANCISCO EDSON OLIVEIRA CASTRO:

Na primeira fase da dosimetria penal, analisadas as diretrizes dos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, "não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também constantes do art. 59, do Código Penal" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.ª ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286). Significa dizer que o legislador explicitou no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, algumas circunstâncias que deverão ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59 do Código Penal, transformando-as em preponderantes. Destarte, em observância às circunstâncias

judiciais previstas no art. 42 c/c art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: a grande quantidade de droga apreendida 11 (onze) porções de maconha (peso bruto - 0,30g), 12 (doze) pedras de "crack" (peso bruto - 0,1g) e 05 (cinco) pinos contendo cocaína (peso bruto - 0,1g), autoriza uma maior reprovabilidade da conduta do réu, razão pela qual aumento a pena-base. b) Antecedentes: o réu ostenta maus antecedentes (fls. 49 - último processo; fls. 50, 51). c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) são neutras, na medida em que inerente ao tipo penal. g) Consequências do crime: entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado não transcendem à espécie, embora reprováveis. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações. Assim, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, isto é, em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a agravante da reincidência (fls. 59 - terceiro processo). Assim, agravo a pena em 1/6, fixando a intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Ademais, na terceira fase, não há como se aplicar a redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº. 11.346/06, tendo em vista a expressiva quantidade de droga encontrada, desvelando não se tratar de mercancia miúda ou esporádica. Ademais, não comprovou ocupação lícita. Ao revés, existe prova de que se dedicava à atividade regular da narcotraficância e pertencia à organização criminosa, a indicar envolvimento sério e detido com o meio.

Cediço é que esse privilégio somente se aplica ao neófito, aquele que, sendo primário, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, absolutamente, não se cuida aqui.

Nesse sentido, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. (I) - REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (II) - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a incidência de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena, bem como a fração a ser aplicada. Incidência do enunciado 7 da Súmula deste STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais. 3. A ausência de particularização dos artigos supostamente violados, inviabiliza a compreensão da irresignação recursal, em face da deficiência da fundamentação do apelo raro. Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, Ag Rg no Agravo em Recurso Especial nº 628.686 MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24/02/2015, pub. em 02/03/2015).

Assim, estabeleço a pena final do réu em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

IV.II - Em relação ao réu LEONARDO KAUE DE VASCONCELOS SANTOS:

Na primeira fase da dosimetria penal, analisadas as diretrizes dos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, anoto que, na lição de Guilherme de Souza Nucci, "não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade de substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias do crime, elementos também constantes do art. 59, do Código Penal" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. I, 6.^a ed., RT, São Paulo: 2012, p. 286). Significa dizer que o legislador explicitou no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, algumas circunstâncias que deverão ser levadas em conta pelo julgador, nos termos do art. 59 do Código Penal, transformando-as em preponderantes. Destarte, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 42 c/c art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: a grande quantidade de droga apreendida 11 (onze) porções de maconha (peso bruto - 0,30g), 12 (doze) pedras de "crack" (peso bruto - 0,1g) e 05 (cinco) pinos contendo cocaína (peso bruto - 0,1g), autoriza uma maior reprovabilidade da conduta do réu, razão pela qual aumento a pena-base. b) Antecedentes: o réu ostenta maus antecedentes (fls. 6 - primeiro processo). c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: entendidos como as razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) são neutras, na medida em que inerente ao tipo penal. g) Consequências do crime: entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado não transcendem à espécie, embora reprováveis. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações. Assim, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, isto é, em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria penal inexistem causas de aumento ou diminuição a serem valoradas.

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Ademais, na terceira fase, não há como se aplicar a redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº. 11.346/06, tendo em vista a expressiva quantidade de droga encontrada, desvelando não se tratar de mercancia miúda ou esporádica. Ademais, não comprovou ocupação lícita. Ao revés, existe prova de que se dedicava à atividade regular da narcotraficância e pertencia à organização criminosa, a indicar envolvimento sério e detido com o meio.

Cediço é que esse privilégio somente se aplica ao neófito, aquele que, sendo primário, empreende pequeno tráfico pela primeira vez, do que, absolutamente, não se cuida aqui.

Nesse sentido, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO DE DROGAS. (I) - REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (II) - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a incidência de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena, bem como a fração a ser aplicada. Incidência do enunciado 7 da Súmula deste STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado constitui circunstância

hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à mingua do preenchimento dos requisitos legais. 3. A ausência de particularização dos artigos supostamente violados, inviabiliza a compreensão da irresignação recursal, em face da deficiência da fundamentação do apelo raro. Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, Ag Rg no Agravo em Recurso Especial nº 628.686 MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24/02/2015, pub. em 02/03/2015).

Assim, estabeleço a pena final do réu em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal.

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica dos acusados (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

V - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO POR PRD OU SURSIS

Diante da reincidência (especificamente em relação ao Réu Francisco), do quantum de pena privativa de liberdade aplicada e da existência de circunstâncias judiciais negativas, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime fechado (artigo 33, parágrafo 2º, alínea "a" do Código Penal) para ambos.

Ademais, o regime inicial deve ser o fechado, na hipótese dos autos, a despeito da extensão da pena carcerária aplicada, porquanto a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas, atingiria um número considerável de usuários, como acima anotado, não autoriza a imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal), além da nítida divisão de tarefas encetada por ambos.

Pelo mesmo motivo, e ainda em virtude do quantum da pena corporal aplicada, os réus não fazem jus à substituição da pena carcerária por restritiva de direitos (cf. artigo 44, incisos I e III, do Código Penal).

Também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do art. 77, do Código Penal.

VI - PERDIMENTO DE BENS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

Amplamente demonstrado, que os bens apreendidos nos autos, eram utilizados para a prática de tráfico de drogas, de rigor o decreto de perdimento dos mesmos.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 07/08) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19.

VII - DA INAPLICABILIDADE DO ART. 387, § 2º DO CPP

Consoante precedentes do TJSP (HC 0122573-89.2013.8.26.0000 e HC 0159595-84.2013.8.26.000), o tempo de prisão cautelar não poderá ser considerado para efeito de progressão de regime, ante a necessidade de exame dos requisitos subjetivos.

Ademais, a Lei nº 12.736/12, que acresceu o § 2º ao art. 387, do CPP, não pode ser aplicada, eis que inconstitucional.

Com efeito, referida lei desrespeita a garantia do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), macula o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e causa inquietações quando à segurança (prevista na cabeça do art. 5º, da CF). O devido processo legal, no âmbito penal, pressupõe a existência de uma fase de conhecimento e outra fase de execução da pena. Antecipar a execução da pena, para a fase de sentença, é tumultuar o feito e usurpar a competência do Juízo das Execuções Criminais. O devido processo legal exige, para a progressão de regime prisional, a observância

das normas instituídas pelos arts. 110 a 119 da LEP (Lei nº 7.210/84). Somente a concentração dos feitos a que eventualmente responde o réu, na Vara das Execuções Criminais, permite a aferição de requisitos como: a) inexistência de condenação superveniente; b) bom comportamento carcerário; c) aqueles, estabelecidos no artigo 114, I a II, LEP; d) os estabelecidos no art. 115, I a IV, LEP; e) a inexistência das hipóteses trazidas pelo art. 118, I a II e parágrafos, LEP.

Estabelece o Código Penal que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração não apenas aspectos quantitativos, relativos à quantidade de pena in concreto estabelecida pela sentença (previstos nos art. 33, § 2.º, letras "a", "b" e "c", do CP), mas também eventual reincidência do acusado e circunstâncias judiciais (consoante estabelece o art. 33, § 3.º, do CP). Significa dizer que a quantidade de pena não é o único critério para a fixação do regime inicial.

Pois bem. O art. 387, § 2.º, do CP estabelece que "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Ora, como se verifica, referido dispositivo legal estabelece mais um critério quantitativo a ser levado em consideração pelo juiz quando da fixação do regime inicial do cumprimento de pena, a par daqueles já estabelecidos pelo art. 33 do Código Penal (ou seja, sem prejuízo da verificação das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da eventual reincidência do acusado).

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena" (STJ, 5.ª Turma, HC nº 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015).

Não há como, na fase de cognição, aferir tais requisitos, especialmente o subjetivo.

Note-se que a execução penal não se destina apenas à concessão de benefícios, de pois de certo lapso temporal, pois ela envolve um juízo de adequação do condenado à sociedade, de modo harmônico e integrado (art. 1º, LEP).

Causa insegurança simplesmente contar o tempo em que os réus estão provisoriamente presos e, apenas com base nisso, fixar regime prisional mais brando, sem levar em conta todas as condicionantes para sua integração à sociedade, de modo harmônico e, repita-se, integrado.

Em suma: esta não é a sede de aferição dos requisitos para uma suposta progressão de regime. Isso compete ao Juiz das Execuções Criminais, definido previamente nas leis processuais (CPP e LEP).

VIII - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para CONDENAR:

A-) o réu FRANCISCO EDSON OLIVEIRA CASTRO, qualificado a fls. 28, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, em virtude da prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, "caput", do Código Penal;

B-) o réu LEONARDO KAUÊ DE VASCONCELOS SANTOS, qualificado a fls. 29, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial fechado, em virtude da prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, "caput", do Código Penal.

Em virtude do teor da presente decisão, notadamente no que tange ao regime de cumprimento de pena fixado, mantenho as prisões preventivas dos Réus e indefiro o

apelo em liberdade, na forma dos arts. 282, 311, 312 e 387, § 4º do CPP. A manutenção das prisões preventivas dos réus se impõe pelo fato de terem permanecido presos durante o curso do processo. Além disso, não se verifica qualquer alteração no cenário levado em consideração no momento da decretação da prisão preventiva, de modo que persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar, reforçados pelo título condenatório.

Saliento que o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória aos sentenciados que responderam ao processo presos preventivamente, precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014. Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. Consequentemente, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública.

Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos sentenciados, pois traficavam expressiva diversidade e quantidade de drogas. Acresça que, em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução